

次の【見解】に関する後記1から5までの各【記述】のうち、誤っているものはどれか。

【見 解】

間接正犯については、被利用者の行為時に実行の着手を認めるべきである。

【記 述】

1. 【見解】は、実行行為時と実行の着手時期が一致することを要しないとする考え方と矛盾しない。
2. 【見解】に対しては、利用者にとって偶然の事情で実行の着手時期を決することになり不合理であると批判できる。
3. 【見解】は、離隔犯において到達時に実行の着手を認める考え方と矛盾しない。
4. 【見解】に対しては、責任無能力者を利用する場合には、責任無能力者に規範意識の障害がないというだけで、直ちに結果発生の切迫した危険があるとはいえないと批判できる。
5. 【見解】は、自然的に観察して結果発生に向けた直接の原因となる行為を重視する考え方と矛盾しない。

【見解】は未遂犯の処罰根拠たる既遂結果発生の具体的危険について既遂結果発生の具体的危険が客観的に切迫したことを要する立場、あるいはその危険を未遂犯に特有の結果と解する立場（結果犯説）から導かれるものである。

1 正しい

【見解】からは既遂結果に至る具体的危険に着目して実行の着手時期が判断されるため、実行行為の開始時と実行の着手時の一致は要しないことになる。よって、【見解】は、実行行為時と実行の着手時期が一致することを要しないとする考え方と矛盾しない。

2 正しい

【見解】は被利用者の行為時に実行の着手を認める考え方である。この考え方によれば、利用行為が終了したとしても、その後の経過につき、利用者の計画通りに進むか否かが不確定である。よって、利用者にとって偶然の事情で実行の着手時期を決することになり不合理であると批判できる。

3 正しい

行為と結果との間に時間的場所的な間隔が存在する離隔犯において、実行の着手時期をどの時点で認めるかにつき、既遂結果に至る具体的危険が生じた時点とする到達時説という考え方がある。

【見解】は、被利用者の行為時に法益侵害の具体的危険が生じたとして、実行の着手を認めるべきであるとする考えであるから、到達時説と親和的である。よって、【見解】は、離隔犯において到達時に実行の着手を認める考え方と矛盾しない。

4 誤っている

責任無能力者を利用して犯罪結果を生じさせようとする場合、利用者がその者を思うがままに利用したといえるため、間接正犯が成立する。この場合、利用者の行為時に実行の着手を認めるという立場からは、利用後の因果経過につき、規範的障害の介在がないから、利用行為時点で、法益侵害への具体的危険が生じると説明される。これに対しては、責任無能力者に規範意識の障害がないというだけで、直ちに結果発生の切迫した危険があるとはいえないと批判がなされている。よって、本記述の批判は、間接正犯につき、利用者の行為時に実行の着手を認めるべきであるという見解に対するものであり、被利用者の行為時にこれを認めるという【見解】に対するものではない。

5 正しい

【見解】は、被利用者の行為時に実行の着手を認める考え方である。この考え方は、利用者の行為時に実行の着手を認める場合と比較して、法益侵害の発生に、より近接した時点での実行の着手を認めるものである。よって、【見解】は、自然的に観察して結果発生に向けた直接の原因となる行為を重視する考え方と矛盾しない。